

1501348-68.2019.8.26.0242

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO HENRIQUE BICALHO CARVALHO

Comarca: Igarapava

Foro: Foro de Igarapava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antônio Carlos da Silva

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos (fls. 22/25), dando-o como incurso nas sanções previstas pelo artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06.
Preso em flagrante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Igarapava

Foro de Igarapava

2ª Vara

Rua Capitão Antônio Augusto Maciel, 130, Igarapava-SP - cep 14540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501348-68.2019.8.26.0242 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501348-68.2019.8.26.0242

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antônio Carlos da Silva

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos (fls. 22/25), dando-o como incurso nas sanções previstas pelo artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06.

Preso em flagrante (fls. 01), foi concedida liberdade provisória sem fiança ao acusado (fls. 68/72), devidamente cumprida (fls. 75/76).

A denúncia (fls. 65/67) foi recebida no dia 1º de outubro de 2019, mesma ocasião em que o réu foi notificado e citado (fls. 68/72).

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 79/84).

A instrução foi realizada, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas de

acusação e, em seguida, realizado o interrogatório do acusado. Na mesma

oportunidade, foi deferida a quebra do sigilo das comunicações dos aparelhos

celulares apreendidos, conforme solicitado pelo Ministério Público (fls. 129/131 e

224 - mídia digital).

O Ministério Público, em alegações finais, pleiteou o acolhimento da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria, tecendo, posteriormente, considerações em cada uma das etapas de dosimetria da pena (fls. 227/233).

A Defesa Técnica do acusado, em alegações finais, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito imputado para o previsto no artigo 28, da Lei Federal n. 11.343/06. Pugnou, ainda, pela fixação da pena no mínimo legal e substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 211/219).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Preliminarmente, não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício. A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

Passo a analisar o mérito.

O réu ANTÔNIO CARLOS DA SILVA foi denunciado porque, supostamente, no dia 1º de outubro de 2019, por volta das 03h00min, na Avenida Mogiana, n. 911, nesta cidade e Comarca de Igarapava/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 05 (cinco) porções de crack, pesando 16,730g (dezesesseis gramas e setecentos e trinta miligramas).

Após regular instrução probatória, a pretensão acusatória merece ser acolhida em parte.

As provas produzidas em juízo não demonstraram com a necessária segurança a ocorrência do crime de tráfico de drogas.

A testemunha de acusação Fransérgio Venceslau Teixeira, policial militar ouvido em Juízo, disse que o acusado é conhecido nos meios policiais como CARLINHOS e existiam várias denúncias via 190 e de usuários acerca do comércio de entorpecentes em sua residência, localizada na Avenida Mogiana, local conhecido pela venda e uso de drogas. Contou que, no dia dos fatos, ANTÔNIO CARLOS estava na via pública sozinho, apesar da presença de alguns usuários próximos, e correu para o interior do imóvel, jogando um objeto atrás da geladeira. Disse que, realizada a abordagem, verificou tratar-se de entorpecentes numa sacola plástica amarela tratando-se de 5 pedras de crack, além de encontrar R\$ 69,00 em notas diversas de R\$ 2,00, R\$ 5,00 e R\$ 10,00 na bermuda do réu e um pote com moedas no valor de R\$ 102,45 em cima da geladeira, bem como outros 2 recipientes com resquícios de drogas e uma lâmina de barbear também com resquícios de crack no local. Contou que ANTÔNIO CARLOS confessou o comércio de crack, que pegou os entorpecentes de desconhecido na noite anterior e que vendia as porções maiores por R\$ 10,00 e as menores por R\$ 5,00 - esclareceu, todavia, que as informações anônimas eram anteriores ao dia em que o acusado alegou comprar as drogas. Declarou que já viu o acusado no local diversas vezes, mas nunca o abordou antes. Informou que apenas o réu estava na casa e a droga estava fracionada, porém num único invólucro. Disse, por fim, que o réu informou não ser usuário de entorpecentes, além de não encontrar resquícios do uso de drogas no imóvel (fls. 129/131 e 224 - mídia digital).

Na mesma linha, o depoimento judicial do policial militar Fábio de Oliveira Sales, que disse que, após solicitação via 190, que noticiou que CARLINHOS estaria realizando traficância em sua residência de número 911, em patrulhamento na Avenida Mogiana, foram visualizados 3 indivíduos em frente à residência de ANTÔNIO, que evadiram-se ao avistar a viatura, além do próprio acusado, que ingressou na residência. Contou que seu companheiro de farda acompanhou o réu e foi em sequência, apontando que o outro policial militar viu o acusado jogar uma sacola plástica atrás da geladeira e, questionado sobre a droga, ANTÔNIO disse que não era usuário, que realizava a traficância de crack por R\$ 5,00 e R\$ 10,00 e que obteve a droga um dia antes. Apontou que tratavam-se de 5 porções de crack, que estavam todas juntas na sacola. Declarou que, em vistoria na residência, foram encontrados mais de R\$ 100,00 em moedas em cima da geladeira e, dentro de um pote plástico,

foram encontrados resquícios de crack, além de uma gilette com resquícios da mesma droga, bem como de R\$ 89,00 em notas diversas encontrados após revista pessoal. Esclareceu que os 3 indivíduos não foram abordados, tendo em vista que CARLINHOS era conhecido dos meios policiais por denúncias anônimas e abordagens anteriores realizadas na mesma avenida. Esclareceu que não observou no imóvel a presença de nenhum petrecho para uso de drogas, indicando a presença de gilettes com resquícios de crack. Apontou que apenas o réu estava no imóvel no momento dos fatos (fls. 129/131 e 224 - mídia digital).

Por sua vez, o acusado ANTÔNIO CARLOS DA SILVA disse que não vende entorpecentes, não tem a "balancinha" e não foi pego vendendo. Declarou que não conhecia os policiais militares e disse que estava vendendo porque ficou assustado, acrescentando que não houve agressão física. Afirmou que os entorpecentes eram destinados a uso, apontando que usou crack por cerca de 3 meses e, após conselhos familiares e sem internação, parou de usar. Falou que não se recorda das 3 pessoas na frente da casa e que estava sozinho na rua. Declarou que o dinheiro era fruto de seu trabalho, que a lâmina era usada apenas para fazer barba e que os 2 celulares apreendidos são dele. Disse que nunca respondeu por nenhum crime (fls. 129/131 e 224 - mídia digital).

Em sede policial, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 05/06).

Embora tenham sido apreendidas 5 (cinco) pedras de crack quando da abordagem do acusado (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo pericial de fls. 14/19 e 103/104), além de recipientes plásticos e lâmina de barbear com resquícios da mesma droga (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo pericial de fls. 105/107), não ficou cabalmente comprovada qual seria a destinação dada aos entorpecentes, especialmente porque nenhum dos policiais militares que realizou a abordagem visualizou ou indicou movimentos relacionados à traficância pelo réu, além dos indivíduos que estariam próximos à sua residência, mas não estavam em contato.

Ademais, o dinheiro fracionado apreendido é apenas um elemento de prova circunstancial, mas que não traz a robustez exigida para a configuração da prática do tráfico de drogas, especialmente porque na residência do acusado foram encontradas apenas 5 (cinco) pedras de crack.

De igual modo, a confissão informal, em que pese configure indício apto a ensejar a instauração da respectiva persecução penal, não foi corroborada por outros elementos de prova, especialmente aqueles produzidos em juízo, de tal modo que nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode ser utilizada exclusivamente para fundamentação de condenação.

Do mesmo modo, não foi possível verificar qualquer indício relativo à traficância nos exames periciais realizados nos celulares do acusado (fls. 165/167 e 168/203). Consigno, ademais, que o réu não ostenta passagens anteriores por tráfico de drogas (fls. 137, 235/236 e 237/273), o que afasta qualquer presunção de dedicação habitual à traficância, apesar das notícias recebidas pelos policiais militares. Assim, tais circunstâncias, aliadas aos demais elementos dos autos não são capazes de demonstrar, sem sombra de dúvidas, que o acusado praticou o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06. Ou seja, os indícios que autorizaram o recebimento da denúncia não se confirmaram em provas concludentes para a condenação do réu por este delito.

Portanto, diante da fragilidade probatória, da quantidade de droga apreendida (13,230g de crack) e, havendo dúvida se os entorpecentes seriam destinados ao narcotráfico, a conclusão deve ser aquela mais favorável ao réu.

Assim sendo, a conduta praticada pelo acusado ANTÔNIO CARLOS deve ser desclassificada para o crime previsto no artigo 28 da Lei Federal n. 11.343/2006, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

"Apreendida pequena quantidade de tóxicos e alegando o réu posse da substância proibida apenas para uso próprio, inexistindo prova de tráfico, impõe-se a condenação do acusado tão somente como usuário."

Tal procedimento não acarreta qualquer surpresa à Defesa, motivo pelo qual se torna desnecessária sua intervenção anterior, eis que se encontra baseado em fatos

devidamente narrados na peça inicial. Neste sentido, STJ, HC 49416/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. em 01.06.06, DJ de 01.08.06.

Nesse contexto, com o deslinde da instrução, razoável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de entorpecentes.

Acrescento ser inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta do réu, vez que a pequena quantidade de droga é própria da natureza do delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Nestes termos, ensina Guilherme de Souza Nucci: "Difere este crime do previsto no art. 33, justamente em face da finalidade específica do agente (consumo pessoal). Não se trata de infração de menor potencial ofensivo, mas de ínfimo potencial ofensivo (...) Denominamos de ínfimo potencial ofensivo o crime previsto no art. 28 desta Lei, tendo em vista que, mesmo não sendo possível a transação, ainda que reincidente o agente, com maus antecedentes ou péssima conduta social, jamais será aplicada pena privativa de liberdade".

Nesse sentido:

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, por ser a posse de entorpecentes para uso crime de perigo abstrato, aliás, a pequena quantidade de estupefaciente é justamente o que a caracteriza, porque a diferencia do tráfico. Condenação mantida. PENA. Estabelecida a reprimenda de prestação de serviços à comunidade, pelo período de dez meses, dada a dupla reincidência do acusado. Manutenção. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1546278-89.2016.8.26.0562; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/06/2019; Data de Registro: 17/06/2019) - grifei.

Apelação Criminal - POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Oitiva de testemunhas - Conduta típica não alcançada pela bagatela penal. Necessidade de proteção do bem jurídico saúde pública - Inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei de Drogas. Inocorrência. Dispositivo, em tese, constitucional. Questão a ser decidida pela e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral - Reprimenda. Adequação - Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1534108-17.2018.8.26.0562; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022) - grifei. Anoto, ademais, que o próprio réu confessou que os entorpecentes destinavam-se ao uso (fls. 129/131 e 224 - mídia digital), de tal modo que não há que se falar em absolvição por falta de provas.

Assim, impõe-se a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 28, da Lei de nº 11.343/06.

Reconhecida, portanto, a ocorrência do delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06 em relação ao réu e a responsabilidade deste, passo à fixação da pena: Na dosimetria da pena, atendendo às circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/06, bem como do artigo 59, do Código Penal, fixo ao acusado a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, com fundamento no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/2006. Ante o exposto, ACOELHO EM PARTE a pretensão acusatória para DESCLASSIFICAR a imputação originária de tráfico para a de posse ilegal de substância entorpecente para consumo pessoal e, desta forma, CONDENAR o acusado ANTÔNIO CARLOS DA SILVA nas penas do crime do artigo 28, caput, da Lei Federal n. 11.343/06, qual seja, advertência sobre os efeitos das drogas.

A prisão provisória foi revogada e não há fundamentos para sua custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), motivos pelos quais o réu poderá recorrer em liberdade.

Transitada em julgado essa sentença: a) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e à Delegacia de Polícia; b) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;

Expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado nos termos do convênio Defensoria Pública/SP e OAB/SP (fls. 32).

Ante a absolvição, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, defiro a restituição dos valores apreendidos (fls. 11/12) e depositados nos autos (fls. 99) ao réu.

Do mesmo modo, desde já defiro a restituição dos aparelhos celulares Blu preto, sem modelo aparente, IMEI n. 352447100201729 e 352447100201737, sem chips, e Alcatel 4009E, IMEI n. 356870067959227 e 356870067959243, contendo dois sim cards da Tim e Vivo, mediante comprovação de sua origem lícita nos autos, após ouvido o Ministério Público.

Se ainda pendente, determino a destruição dos entorpecentes apreendidos, nos termos do artigo 72 da Lei Federal n. 11.343/06.

Desnecessária a inclusão do nome do condenado no rol dos culpados, tendo-se em vista a revogação do artigo 393 do Código de Processo Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça que neste ato concedo.

Cumpridas todas as formalidades legais, ao arquivo.

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.

Igarapava, 21 de julho de 2022.

Pedro Henrique Bicalho Carvalho

Juiz de Direito

2ª Vara da Comarca de Igarapava/SP

(assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/2006)